

1518864-61.2020.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... defensiva e não reconheceu a configuração do tráfico.

Apelação - Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) -

Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Recurso do Ministério Público - Réus flagrados na posse de 487g de maconha -

Desclassificação correta - Quantidade compatível com uso pessoal para os dois acusados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518864-61.2020.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518864-61.2020.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282829/2020 - DEL.POL.ILHA

COMPRIDA, 14659660 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 1560/20/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA,

2282829 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CÉZAR DOMINGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c 41 do Código de Processo Penal, em face de Thiago César Domingos - qualificado nos autos - imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia de fls. 91-93 oferecida pelo Parque:

"(...) no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 17 horas, em terreno situado na Rua Pacheco dos Santos, nº 1.575, Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, THIAGO CÉZAR DOMINGOS, qualificado a fls. 04, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, quatorze porções de cocaína,

com peso bruto total de 7,06g (sete gramas e seis centigramas), trinta e duas porções da mesma substância, na forma de pedras de "crack", com peso bruto total de 10,13g (dez gramas e treze centigramas), e vinte e uma porções de maconha, com peso bruto total de 58,58g (cinquenta e oito gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de constatação a fls. 12/13, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e imagens às fls. 36/40).

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, um terreno baldio, o denunciado trazia consigo uma porção de crack e guardava, no interior de uma sacola plástica escondida no terreno, as demais drogas acima mencionadas, embaladas individualmente, para entrega a consumo de terceiros.

Todavia, nesse momento, o denunciado foi abordado por policiais militares que, em revista pessoal, encontraram a porção de crack e a quantia de R\$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), em notas fracionadas.

Em vistoria ao local, os policiais encontraram as demais drogas.

Ressalte-se que não é a primeira vez que o denunciado é processado criminalmente pela prática de crime de drogas, como se verifica a fs. 50/52.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, a vultosa quantidade e variedade de drogas, o modo de embalagem, a vultosa quantia sem comprovação de procedência e a prática de crimes anteriores, resta evidente que as drogas se destinavam ao tráfico ilícito."

Preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 71-77).

Recebida a denúncia, determinou-se a citação do acusado (fls. 95-96).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal (fls. 146-152).

Ausentes os elementos capazes de levar à absolvição sumária do réu, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 165-169).

Durante a audiência, colheram-se os depoimentos de duas testemunhas. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado. (fl. 187).

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, aditando a denúncia e pugnando pela parcial procedência da ação, para desclassificar a imputação pelo crime de tráfico de drogas e condenar o réu como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, postulou pela improcedência da denúncia, para que fosse o acusado absolvido nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Em atenção ao princípio da eventualidade, requereu a desclassificação da conduta do acusado para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 5-9), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12-13), pelas imagens de fls. 36-40 e pelo laudo pericial das drogas (fls. 135-139). Do exame desses documentos, concluiu que foram encontrados 14 invólucros plásticos contendo 6,10g de massa líquida em que foi detectada a presença de cocaína, 32 invólucros plásticos contendo 6,10g de massa líquida em que foi detectada a presença de cocaína na forma de pedras de crack, e 21 invólucros plásticos contendo 49g de massa líquida em que foi detectada a presença de "maconha", cujo uso é proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria será analisada.

Durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Marco Antonio Carravieri Oliva Júnior (Policia Militar) disse que estavam em patrulhamento pelas mediações da av. Copacabana, quando por meio de denúncias anônimas ficaram sabendo de um indivíduo alto e moreno traficando drogas no local dos fatos. Ao adentrarem na via, já visualizaram o acusado, que tinha as mesmas características reportadas, saindo de um terreno. Abordando o acusado, encontraram com ele certa quantidade de dinheiro e uma porção de crack. No lote onde ele foi encontrado havia uma porção maior de drogas. Thiago disse que apenas foi ao terreno

urinar. O local dos fatos é conhecido pela prática de tráfico. As características do réu bateram com o reportado pelas pessoas que encaminharam a denúncia. Nunca havia abordado Thiago.

Rodrigo de Castro Carvalho Ribeiro (Policial Militar) apresentou versão semelhante à de Marco. Acrescentou que Thiago confirmou que estava vendendo drogas desde a parte da manhã.

Advertido dos seus direitos constitucionais, o acusado optou por exercer sua autodefesa. Em seu interrogatório, Thiago César Domingos disse que no dia dos fatos estava fazendo um serviço de limpeza de terreno. Recebeu o valor de 200 reais em uma única nota em pagamento aos serviços prestados. Continuou executando o serviço, porque não havia terminado. Concluiu o serviço quase 17h00. Após terminar o serviço, pegou as ferramentas pertencentes ao vizinho, consistentes em enxada, pá e carrinho de mão. Passou no local dos fatos para comprar crack. Assim que chegou no local de venda de drogas, deixou o carrinho de mão ao lado da calçada. Havia um casal que fazia a venda. Ao fundo desse local tem um muro de aproximadamente 1m, dando acesso à rua de trás. Quando foi adquirir a droga, deu a nota de R\$200,00 ao traficante, recebendo o troco de R\$155,00 em notas fracionadas. O traficante perguntou ao interrogando se poderia completar o troco com R\$15,00 em moeda, ao que afirmou positivamente o interrogando. Enquanto o traficante contava as moedas, a mulher que o acompanhava avisou que a viatura policial estava passando. Nesse momento, o traficante disse ao interrogando para pegar as moedas depois e saiu correndo. Quando o interrogando estava saindo do terreno, os policiais o viram. O interrogando já havia pegado três pedras de crack, no porte das quais pegou suas ferramentas e caminho em direção à viatura. Quando foi abordado confessou aos policiais que adquiriu a droga para consumo próprio de um rapaz. Os policiais pressionaram o interrogando para prestar informações sobre o traficante, de modo que, se ele não as fornecesse, iria ser responsabilizado, sem, no entanto, saber sobre o quê. Diante disso, reafirmou que comprou a droga para consumo próprio, que estava há pouco tempo na cidade e que não conhecia quase ninguém. Disse aos policiais que conhecia a cidade em razão da sua mulher, com quem não está mais junto. Os policiais disseram ao interrogando que ele deveria explicar aquela situação ao delegado, conduzindo-o até a delegacia. Em nenhum momento, no entanto, os policiais mostraram as drogas apreendidas ao interrogando. O Delegado não estava na delegacia e, então, ficou na cela. Após a chegada do delegado, narrou os fatos. O delegado lhe informou que a imputação que recaía sobre o acusado não era apenas das três pedras de crack. Acredita que imputam o crime de tráfico ao interrogando porque ele não disse onde o traficante morava, mas realmente não sabia onde era, pois, do contrário, teria colaborado com os agentes. Por isso, o delegado lhe falou que não poderia soltá-lo, pois poderia ser responsabilizado e deixaria a decisão da questão para o Ministério Público e o juízo. Foi abordado primeiro pelo Policial que compareceu em audiência, sem farda, enquanto o outro policial, fardado, entrou no terreno atrás das pessoas. A guarnição tinha visão do local onde o interrogando comprou a droga das pessoas que realizaram a venda. O policial que foi ao terreno foi atrás das pessoas que lhe venderam a droga. Em nenhum momento confessou a prática de tráfico de drogas. Confessou apenas o uso de drogas.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. In casu, apesar do réu ostentar condenações anteriores por tráfico de drogas, pairam dúvidas acerca do contexto fático e probatório em que ocorreram os fatos. Tem-se que o suposto envolvimento do réu com a comercialização de drogas decorre única e exclusivamente de denúncias, cuja identidade dos autores se desconhece por completo, feitas aos policiais que fizeram a abordagem. Em outros termos: os policiais ouviram falar que o réu estaria vendendo entorpecentes.

De acordo com a denúncia e com o relato dos policiais que fizeram a abordagem, em posse do acusado foi encontrada apenas uma porção de crack que, apesar de ser uma droga que tem grande potencial de causar dependência, a quantidade se revelou ínfima.

Ademais, o réu alega com veemência que em momento algum confessou a prática de tráfico, e sim a condição de usuário.

Compulsando os autos e o contexto narrado tanto pelos agentes públicos como pelo réu, é crível que o acusado esteja dizendo a verdade. Alias, os policiais não viram o acusado na posse do restante das drogas. Portanto, reputo haver dúvida razoável acerca da efetiva comercialização de drogas por parte de Thiago.

Como se sabe, segundo a vertente probatória do princípio da presunção de inocência, incumbe ao Ministério Público demonstrar, além de dúvida razoável, que o réu cometeu a infração penal descrita na denúncia.

As provas produzidas, portanto, revelam-se frágeis, não permitindo o reconhecimento de que o material apreendido efetivamente se destinava à comercialização.

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

A partir desses dispositivos, não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após presidir a instrução do feito, colher as provas necessárias para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da adequada interpretação do art. 156 do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo, trago à baila as lições do Professor Afrânio Silva Jardim:

[...] somente a acusação é que alega fatos, atribuindo-os ao réu. Eventual 'alegação' deste, será tão-somente aparente, vez que juridicamente deve ser reputada como mera negação dos fatos alegados na denúncia ou queixa", isso porque, no processo penal, o réu é presumidamente inocente e a dúvida sempre o favorece. Sob tal prisma, não é aplicável de forma automática, no processo penal, a distribuição do ônus da prova regulada no processo civil, de forma a transferir ao acusado o dever de demonstrar sua inocência. Urge que a regra do art. 156 do CPP seja compreendida como "a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 294-312).

Acerca do tema, trago à baila precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que, mesmo diante da apreensão de quantidade significativa de droga, acolheu a tese defensiva e não reconheceu a configuração do tráfico.

Apelação - Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Recurso do Ministério Público - Réus flagrados na posse de 487g de maconha -

Desclassificação correta - Quantidade compatível com uso pessoal para os dois acusados - Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância - Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância - Operada, no curso do processo, a desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes, de rigor a proposição de transação penal e de suspensão condicional do processo - Benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e Maus antecedentes - Conversão em diligência para que o representante do 'parquet' avalie eventuais propostas.

(TJSP; Apelação Criminal 1511721-06.2019.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

No mesmo sentido:

TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. Ao ser interrogado em juízo, o réu apresentou versão lógica e coerente, que traduz a impressão de condizer com a realidade. O réu, em juízo, negou a prática delituosa tráfico. Portanto, fato é que os policiais (ou quem quer que seja) não viram o réu realizando qualquer conduta típica da traficância. Apenas apreenderam pequena quantidade de drogas. FALTA DE PROVAS. Assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a melhor solução para o caso é a desclassificação da imputação para a modalidade prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, pois, inegável que em poder do apelante foi apreendida parte da droga, porém a mesma se destinava ao seu uso pessoal. (TJSP; Apelação Criminal 1500342-80.2020.8.26.0633; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

Portanto, como o órgão de persecução penal, mesmo após a instrução processual, não logrou êxito em convencer o juízo de que o réu praticou a infração descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de rigor a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.

In casu, conforme se extrai de fls. 97-104, o acusado se encontra preso preventivamente desde novembro de 2020.

A partir do momento em que a instrução criminal aponta por crime diverso daquele ensejador da prisão em flagrante, sobretudo tratando-se de delito não punido com pena privativa de liberdade, incoerente se torna a imposição de qualquer outra pena.

Solução, nesses casos, é a aplicação do mesmo entendimento da detração na pena de multa, isto é: aplica-se, por analogia, no desconto da pena de multa o tempo de prisão provisória. Assim, quem foi preso preventivamente para, ao final, ser condenado apenas à pena pecuniária não terá nada a cumprir.

Destarte, em consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do réu, o qual já cumpriu pena mais severa daquela prevista no preceito secundário da norma transgressora.

A propósito:

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Abordagem policial realizada a partir de precisa notícia anônima acerca de uma entrega de droga que seria realizada pelo réu. No local indicado, o acusado foi flagrado com terceiro indivíduo, o qual logrou êxito na fuga, sendo abordado e consigo apreendidas 4 porções de maconha. Após incursão na residência do réu, acompanhada pela genitora, os agentes públicos apreenderam mais 12 porções da mesma droga, totalizando massa líquida de 378 gramas de maconha. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório. Possibilidade. Reduzido volume de droga e ausência de outros elementos contundentes que demonstrem a posse para fins de fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Ilógica aplicação de qualquer pena. Prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo revogada por força de habeas corpus. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500407-46.2020.8.26.0578; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Arguição da inconstitucionalidade da criminalização da posse de drogas para uso próprio. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) readequação do aumento operado na segunda fase; c) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; d) fixação do regime inicial diverso do fechado. Prequestionamento da matéria ventilada no recurso. 1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de

drogas. Negativa do réu. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 2. Da tipicidade da conduta. Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Recurso Extraordinário nº 635.659 ainda pendente de julgamento. Norma penal que tem como objeto a tutela da saúde pública. Precedentes. 3. Dosimetria. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Réu reincidente. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 4. Recurso provido. Revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500640-90.2021.8.26.0066; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para DESCLASSIFICAR a conduta de Thiago César Domingos para o tipo penal constante no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e DECLARAR extinta a punibilidade pelo cumprimento de pena, com base no art. 42 do Código Penal.

Inviável a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da Lei.

Determino a destruição da droga, na forma do art. 72 da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e no cadastro da Corregedoria-Geral da Justiça; (b) oficie-se ao Juízo Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Iguape, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA